

鑑定意見書

大阪府外形標準課税条例の適法性について

立命館大学法学部教授
博士(法学・一橋大学)

目次

- I はじめに
- II 鑑定意見書の結論
- III 大阪府税条例と地方税法
 - III-(1) 地方税法72条の19と本件条例
 - III-(2) 近郊要件と本件条例
 - III-(3) 不均一課税と本件条例
 - III-(4) 法定外税手続と本件条例
 - III-(5) 本件条例と憲法
- IV おわりに

I はじめに

筆者は長年税法の研究に従事してきた。このたび、大阪府から専門の立場から「大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等に関する条例(以下、「本件条例」と略す)の適法性についての意見を求められた。専門家としての公正な立場から意見を申し述べるものである。

II 結論

まず結論を要約しておきたい。

以下において、より詳細に上記結論の理由を述べることにしたい。

東京地裁民事3部が3月26日に示したいわゆる銀行税条例判決(以下、地裁判決と略す)は大きな衝撃を与えた。同条例を地方税法72条の19に反し違法、無効との判断を下したからである。導入時には肯定的に報道してきたマスコミの多くが手のひらを返したように銀行税の問題を指摘し、それに同調する意見も多く掲載され、ついには大阪府も徴収を1年延期する内容の修正をするに至っている。その意味で、同判決の果たした影響は計り知れないものがある。しかし、その判決内容は本当に事業税を法的に精査したうえでなされたものなのであろうか。判決文を読み直すたびに、なぜこのような基本的な誤解をした判断が、複数の裁判官が関与するはずの税務訴訟においてなされてしまったのか、という疑問を抱かざるを得ない。地裁判決は、最初に東京都敗訴の結論を出した上で、結論を合理化するために税法の解釈を相当強引に歪め、場合によっては初歩的な誤解をしたまま結論を正当づけている、とわざるを得ないからである。それだけに、このような判決が地方税制に大きな影響を与えることに強い懸念を覚えるとともに、高裁で現行事業税法の法的仕組みが公正に精査され、より正当な判断が示されることを願っている。

本稿では、地裁判決の問題点を指摘しつつ(1)、事業税の法的構造を重視する観点から地裁判決の論拠を批判しておきたい。

一 事業税の沿革…恣意的で強引な事実認定

地裁判決の論理を要約すると以下ようになる。

①事業税は現行地方税法では所得を課税標準とする「所得」税である。②従って、所得以外の課税標準を採用するには慎重でなければならず、「事業の状況」も厳格に解さねばならない。③そこで、所得以外の基準で課税しうる「事業の状況」とは、現行地方税法の例外4業種に匹敵するような事情がある場合に限定され、事業自体の客観的性格や法律上の特別な制度がある場合にしかできない。④しかし、銀行業にはそのような事情はなく、単にバブルの崩壊によって一時的に所得が減少したにすぎない。⑤従って、そのような銀行業に所得以外の基準で課税しうる「事業の状況」があると判断して制定された銀行税条例は違法である。

しかし、地裁判決の論理はその前提である①の出発点のところで根本的に誤っていると言わざるを得ない。地裁判決は①の論理を正当化するために、まず事業税の変遷過程等に言及し、結論として「このような経緯からすると、25年法が採用した応益的な考え方は、事業税の賦課を正当化する理由ないしは制度の理想として所管官庁において維持されていたものの、これをそのまま税制に反映させることは納税者の能力を超えるものであったことから、これを廃止せざるを得なくなり、現実の税制としては、納税者の能力に応じた所得課税を基本とする制度を維持せざるを得なかったものということができる」と断定している。

従って、事業税は「所得」を課税対象とする応能的租税として導入されたというのであるが、そうすると事業税について旧自治省関係者によって書かれた解説書はみな誤った解説をしてきたことになる(2)。このような大胆で、従来の理解と著しく異なる断定をする以上、立法過程についてより慎重な検討がなされていなければならないはずであるが、地裁判決で示されている立法事実は、結論に都合の良い部分のみを引用するという公正さを欠いた一面的なものとなっている(3)

出発点でこのような杜撰な認定をし、しかもそれを結論に直結させていることに驚くが、逆に言うと、このような強引な認定をしなければ、その後の論理を引き出せなかったのであろう。残念だが、

地裁判決は、「はじめに結論ありき」の姿勢で事実認定をしてしまったと言わざるを得ない。

二 事業税の法的性格

地裁判決は、上記の大胆な認定と実定地方税法の条文とをつなげて次のように説明しているので、一見解釈論としてあり得るかのような印象を与える。「以上のような経緯を前提として、現行の法人事業税についての定めをみると、課税標準については、地方税法72条の19(これは72条の12のミスであろう…筆者注)により『法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業にあっては各事業年度の収入金額、…(中略)…その他の事業にあっては各事業年度の所得及び清算所得による。』と定められ、課税標準は、原則として『各事業年度の所得及び清算所得』とし、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業の例外4業種については例外的に『収入金額』としている。したがって、少なくとも現行地方税法の解釈においては、地方税法72条の12が大半の業種について所得を課税標準としていることから、事業税が『所得課税』という意味での応能課税の立場を原則としていることは否定できない。」

地方税法72条の12の条文を重視して、そこから事業税の性格を引き出し、事業税は所得課税だとしているわけである。しかし、この解釈方法は地方税法の条文解釈方法として基本的な誤りをおかしている。その論拠を少し示しておこう。

まず第1に、租税の法的性格を一つの条文だけから引き出すことは誤りである。例えば、消費税法28条をみると、「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする」と規定されている。地裁判決のように解釈すると、消費税の法的性格は課税標準が譲渡の対価とされているので、売上税(取引高税)であり、いわゆる付加価値税ではない、ということになる。このような解釈は誤りであるし、現実には消費税を売上税として説明するものは誰もいない。なぜならば、消費税の条文を体系的に理解すれば、この課税標準自体は売上税的な規定内容になっているが、他の条文で仕入税額控除の仕組みを組み込んでおり、従って、その法的性格は付加価値税であることは言うまでもないからである。各租税の法的性格は課税標準規定だけではなく、条文全体を体系的に理解して判断すべきことは、法解釈の常識のはずである。事業税についても条文を体系的に調べた上で判断すべきであり、地裁判決にそのような慎重さがあれば、確かに地方税法72条の12だけから判断すれば所得が原則であるかのように見えないではないが、その前に地方税法は72条で「事業税は、法人の行う事業に対し…法人にあっては所得及び清算所得又は収入金額…を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その法人及び個人に課する」ことを明言していることに容易に気づいたはずである。地方税法は、原則として課税標準に使う基準として所得と収入に優劣をつけていないし、その本質は「所得」ではなく「事業」に対して課されるものであることも明記しているのである。従って、72条の12という一つの条文から所得課税であるという結論は出てこないし、同条文自身が例外としてであれ収入金額を課税標準とする余地を認めていることは、事業税の本質が所得課税ではないことを逆に示しているのである。

第2に、地方税法は事業税が所得課税ではないことを他の条文で明らかにしている。例えば、72条の14では課税標準は法人税法の所得そのものではなく、各種の加算減算をすることを要求している。これは、本質的には事業税の課税標準を所得に依拠しつつも事業規模にふさわしいものに修正するための規定である。もっとも、わが国の地方税法72条の14は技術的な修正にとどまっているので、この点が見えにくくなっている。しかし、わが国の地方税法は72条の15で、海外の所

得を除外することを独立の条文で規定している。この条文は、事業税が所得課税ではなく、事業そのものを課税客体とするものであり、「事業とは国内における事業と解される」(4)ことを明らかにするための規定である。地裁判決のように事業税を所得課税だとするのであれば、海外の所得を課税標準から除くことを合理的説明することは不可能である。そのためか地裁判決はこの点には沈黙している。また、事業税が所得課税なら、所得税法上の所得に含まれるにもかかわらず、事業税の対象にはなっていない農業所得や林業所得の存在をどう説明するのか、という疑問もある。

また、事業税が所得課税だとすると、その場合に現行法が事業税を所得計算に際して損金としていることを(法人税法38条3項参照)どう説明するのだろうか。所得課税であれば、事業税は「所得」に税率をかけて求められるべきものだから所得計算過程で控除してはならないはずである。この点を、判決は「これらは、あくまで所得税法及び法人税法がそれぞれ所得税及び法人税の課税標準を算出するに当たって事業税をどのように扱うかという技術的な規定にすぎない」と逃げている。事業税を所得課税であると理解すると論理的に説明できない現行法の制度を「技術的なもの」に退けているのである。しかし、「所得」課税である租税を「所得」から控除したら、課税標準としての所得の算定は不可能になりかねないのであって、単なる技術的なものではないのである。

第3に、仮に地裁判決のように事業税を所得課税であるとすると、現行の道府県民税と抵触し、同一の課税団体が同一の課税標準に二重の課税をすることになってしまう。二重課税を禁止する規定はない、という反論があるが、これはそもそも立法上の当然の原理であり、既存の税制と課税理念、課税対象、課税標準等が同一なら、何も新税を導入する必要はなく、税率を調整すべき問題であることは何人も否定しえないであろう。現行地方税法の立法者が、住民税とは別個に事業税という税目を都道府県に導入したのは、住民税とは別個の課税理念、課税対象を想定していたからであり、一見課税標準が住民税と似ているからといって、住民税同様所得を課税対象とする租税だと解したら、何のために事業税が導入されているのか全く説明できないであろう。立法者は二重課税にならないように新税を導入しているという当然の前提を理解した上で、条文全体をすこしでも調べれば、事業税が住民税と同一の所得課税などではないことは容易に理解できたはずであるし、事業税を体系的に解釈できたはずである。また、事業税を所得課税と解すると法人税法158条の付加税禁止にも抵触する可能性があるが、地裁判決は「同条は、他の租税の税額を課税標準として課される租税という意味での狭義の『附加税』を課すことを禁じたものであって、他の租税の課税標準を課税標準として課される租税という意味での広義の『附加税』を課すことを禁じたものでないことは、法人住民税に関する規定(地方税法23条以下、292条以下)をみても明らかであり、現行の法人事業税は、法人税の税額を課税標準とするものではないから、同条にいう『附加税』に当たらない」と説明している。この説明は、法人住民税に法人税割がないことを前提としないと成り立たない反論であり、現行地方税法を誤解したまま被告の主張を退けているとは思われない。

三 事業税と応能原則

地裁判決の奇妙さは、以上のような立法過程の認定や、条文解釈にとどまらない。租税の基本原則についてもいくつかの重大な誤解をしているように思われる。

まず、地裁判決は応能原則を次のように強調する。「具体的な租税法令を解釈するに当たっては、特別な規定がない限りは、上記の租税の基本的性格にしたがって、応能原則により課税されているものと解釈をすべきであり、しかも、憲法14条の定める平等原則からすると、一般に租税は担税

力に応じて負担させるべきものであって、担税力との均衡を著しく失する課税には憲法上の問題も生ずるところであり、応能原則はこのことを課税法律関係において実質的に担保する働きを持つものといえることができる」。

筆者も応能課税が憲法上の原則だと強調してきた立場なので、地裁判決のいう基本理念には共鳴するものがあるが、だからこそこの判決には疑問があるのである。というのは、地裁判決は憲法上の原則は応能課税だから、事業税は所得課税である、つまり、応能課税＝所得課税というきわめて短絡的な理解をしているからである。

確かに所得課税は応能課税に適合的だが、それは地裁判決が安易に前提にしているように「所得」課税だからではない。所得課税であっても物税的に構成して単純に「所得」そのものに課税するシステムが採用された場合、それが憲法の応能課税原則に反することもありうることに留意しなければならない。たとえば、高齢の両親や幼い子供を扶養しているAさんと独身のBさんが同額の所得を得れば同額の税負担になるようにすることも「所得」税では可能である。しかし、それではあまりにも負担の公平を歪めるので、扶養控除等の各種の人的控除を通じて納税者自身の人的負担能力を配慮しているのであり、それが所得課税の応能化に貢献しているのである。つまり、単に所得課税だから応能であるわけではなく、所得課税は人税的に構成しやすいから応能原則に適合しやすい税制なのである。事業税が課税標準にしている「所得」はこのような所得ではないことを地裁判決は見落としている。なぜなら、事業税が課税標準にしているのは、個人事業については「事業の所得」であり、事業主控除を除いては所得税のような人的控除はないからである。つまり、事業税は所得を物税的に課税する制度であり、所得税のような人税とは根本的に異なっており、その意味で、個人の担税力に着目したものではなく、事業そのものの担税力としての事業所得に着目した税なのである。地裁判決は「人税」と「所得課税」を混同したまま、事業税＝応能課税＝所得課税だとしていることになる。

なお、地裁判決が強調する応能原則を実現するには、人的控除だけではなく、他の方法もあり得る。例えば、法人税の場合は、会社が利益追求を目的とした社団であることから人的控除の余地がない。従って、各企業が有している負担能力をさしあたりは所得のみで測り、資本金による負担能力の差を税率面で配慮していることなどがその例としてあげられよう（法人税法66条2項参照）。

いずれにせよ、地裁判決が強調する応能原則は課税標準を所得にすることのみで実現されるものではないし、負担能力の指標を何に求めるのかによってあるべき税制像も異なってくるのである。また、地裁判決は応能課税と応益課税を対立的にとらえているが、応益課税の課税根拠となる「受益」の意味の理解如何によっては応能課税と重なる部分も多く、決して対立的にとらえるべきではないのである。東京都や大阪府の銀行税の目的は、私見によれば、事業規模から推定される負担能力に応じた公平な課税の実現だったと思われる。

四 事業の情況

事業税が所得課税だとする判決の論理からすれば、所得以外の課税標準の採用を認める「事業の情況」は当然厳格なものになる。地裁判決は、その基準として「当該事業の収益構造や法律上の特別の制度の存在など当該事業が順調に行われていてもなお所得が担税力を適切に反映しないといた事業自体の客観的情況」と解している。しかし、このような限定厳格解釈は基本的に誤っていると言わざるを得ない。

まず第一に、例外4業種とほぼ同様の基準が必要であるというなら、そのような事情はなにも自治体が条令制定をするまでもなく地方税法の改正で対処しうるものであろう。「法律上の特別な制度」を設けるときに国が地方税法を改正すればすむことだからである。

第二に、仮に地裁判決に従うと、自治体がこの条文から独自に条例を制定出来るのは、当該自治体内に例外4業種と同様な客観的事実がある場合に限定されることになるが、例外4業種と同様に認可制による料金規制や法律上の制度が設けられるような事業が特定の自治体内に存在することを想定することは不可能である。実際には使えない特例を地方税法がわざわざ設けたことになる。

第三に、何よりも同条の規定からみて判決のような著しく限定した解釈は不合理だと思われる。なぜならば、地方税法第72条の19は「法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、・・・所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる」としてしか規定していないからである。地裁判決のような前提で立法されているならば「法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準についても、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業事業と同様の事業の情況が認められる場合には・・・所得以外の課税標準を用いることができる」というような規定になっていたはずである。事業税を応能課税だと断定する際には、事業税の課税標準が所得になっている72条の12の条文を重視しておきながら、72条の19になると条文は無視して目的解釈に転換している。地裁判決の解釈方法は論理的ではないし、一貫もしていない。誤った結論にすべての条文を強引に結びつけていると言わざるを得ない。

おわりに・・・なぜこのような判断がでてくるのか

地裁判決は、以上のような誤った前提に立って、東京都の銀行税条例を地方税法違反とし、さらに、主税局の過失まで認定している。しかも、その際「銀行の業務粗利益が一般事業会社の売上総利益に相当するものでないことは、本件において被告らも認めているところであり、それは、前者が貸倒損失を控除していない点にある」という前提に立って、「東京都主税局長は、都議会において、現行の事業税につき、所得課税という応能原則による課税が行われていることを認識しながら、あくまでこれが応益原則に基づくものと強弁し、かつ、銀行の業務粗利益が一般事業会社の売上総利益に相当するとの誤った説明を行い、都議会議員らの判断を誤らせるに至ったのであるから、これらについての過失が問われなければならない」と断定している。

しかし、すでに多くの論者が指摘しているように(5)、売上総利益は「売上高」から「売上原価」を控除した、いわゆる「粗利」であり、損益計算書上、貸倒損失を控除する前に計上されているのであって、両者はいずれも貸倒損失は控除されていないのである。従って、「前者が貸倒損失を控除していない点にある」と理解している地裁判決自体が誤っているものであり、このような誤解を前提に東京都の「過失」を断罪していることになる。

このように、地裁判決は詳細な判例評釈をする以前のところであまりにも重大な誤りを犯しているように思われる。地方税法を体系的に精査した上で解釈しないで、応能課税＝所得課税とする単純な理解から東京都の主張を退け、東京都の主張を支持する意見書を「一つの財政学的見地からの法人事業税のあるべき姿を立法論としていうもの」として片づけている。この評価は、むしろ地裁判決そのものにふさわしい評価である。わが国の税務訴訟では納税者の勝訴率が低すぎることを懸念してきたが(6)、このような判決内容で納税者が勝訴するものやはり問題であろう。ドイツの財政裁判所のような税法専門裁判官による税法専門裁判所の必要性を改めて強調せざるを得ない。

- (1) 地裁判決については、すでに税研103号において、佐藤英明、岩倉正和、占部裕典、多田雄司、粕谷晴江、戸松秀典の各氏による評釈、北野弘久『『銀行税条例』違法判決批判』税経通信2002年6月号35頁以下、等の評釈がある。筆者自身も東京税務レポート444号2頁以下に「銀行税東京地裁判決への疑問」として、同判決の問題点を指摘したことがある。また、東京都税務レポート445号には同判決に対する特集が組まれる予定のようである。
- (2) 旧自治省関係者の事業税に関する書籍では、「事業税は事業を行うという事実に着目して、事業そのものを課税客体とし、事業の規模ないし活動に応じて課する性格の税である」(松尾徹人・小林弘明・折笠竹千代『自治行政講座・第10巻・地方税Ⅰ』第1法規、昭和61年、452頁)と解説されるのが一般であった。これらの説明はみな誤りだったことになる。
- (3) 地裁判決のこの部分についての批判としては、佐藤英明・前掲税研103号の評釈も参照。また、控訴人の控訴理由書がインターネットで公開されており、参考になる。
<http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2002/200205a.htm>。
- (4) 自治省府県税課編『事業税逐条解説』(地方財務協会・1995年)213頁。
- (5) 北野・前掲論文40頁、粕谷・前掲論文68頁。
- (6) この点については、三木義一編『世界の税金裁判』(清文社、2001年)の序章を参照いただきたい。

銀行税東京地裁判決への疑問

三木義一(立命館大学法学部教授)

はじめに

さる3月26日東京地裁が東京都のいわゆる銀行税条例について、地方税法72条の19に反し違法、無効との判断を下した。しかし、その判決内容には地方税法の解釈として首をかしげざるを得ない箇所がすくなくない。その問題点と思われるところを、少しわかりやすく解説してみたい。

一 銀行税条例の適法性判断の二つの視点

今回問題となった銀行税条例は、原則として法人税法上の所得をベースとした課税標準を採用している事業税の特例として、銀行については地方税法72条の19の「事業の情況」があるとして「所得」ではなく、「業務粗利益」を課税標準として課税するものであった。

この条例の地方税法72条の19適合性を判断するに際しては、基本的に次の二つの視点がある。

①事業税は現行地方税法では所得を課税標準とする「所得」税である。→従って、所得以外の課税標準を採用するには慎重でなければならない。「事業の情況」も厳格に解さねばならない。→そこで、所得以外の基準で課税しうる「事業の情況」とは、現行地方税法の例外4業種に匹敵するような事情がある場合に限定され、事業自体の客観的性格や法律上の特別な制度がある場合にしかできない。→しかし、銀行業にはそのような事情はなく、単にバブルの崩壊によって一時的に所得が減少したにすぎない。→従って、そのような銀行業に所得以外の基準で課税しうる「事業の情況」があると判断して制定された銀行税条例は違法である。

②事業税の本質は所得税ではなく、事業自体に担税力を求めた税である。→従って、所得以外の基準で課税するのが本来は望ましいが、他の基準で課税するには様々な困難があったために「所得」で一応課税してきている。→しかし、そのために地方税法は「事業の情況」に応じて所得以外の基準で課税する余地を認めており、この「事業の情況」というのは所得で課税すると不合理になる事情を広く含むのであり、それが地方自治の精神にもかかなう解釈である。→従って、バブル崩壊後不良債権処理のため所得が発生しないため事業税負担が著しく軽くなっている一定の銀行業に対して業務粗利益で課税するとしている銀行税条例は何ら地方税法に反していない。

①が銀行、②が基本的に東京都の主張であり、私自身は②の方が現行地方税法の解釈として正当だと考えている。地裁判決はほぼ全面的に①の主張を採用して、東京都側の主張を退けてしまった。しかし、その判断の前提にはかなり誤った応能課税原則に対する理解があり、その前提のまま誤った結論を導いてしまっているように思われるので、少し問題点を整理しておきたい。そのためにも、地裁判決の論理を少し紹介しておこう。

二 東京地裁判決の論理

判決はまず事業税の沿革を検討した上で、結論として次のように事業税の性格を断定している。「このような経緯からすると、25年法が採用した応益的な考え方は、事業税の賦課を正当化する理由ないしは制度の理想として所管官庁において維持されていたものの、これをそのまま税制に反映させることは納税者の能力を超えるものであったことから、これを廃止せざるを得なくなり、現実の税制としては、納税者の能力に応じた所得課税を基本とする制度を維持せざるを得なかったものといえることができる。」

要するに判決は、理論的にはともかく、現実の地方税法は事業税を所得課税として規定せざるを得なかった、と認定したわけである。

そうすると、所得以外の課税標準を採用できる「事業の情況」は当然限定されてくることになる。しかし、他方で、判決は応能課税の原則を一旦強調する。すなわち、「少なくとも現行地方税法の解釈においては、地方税法72条の12が大半の業種について所得を課税標準としていることから、事業税が『所得課税』という意味での応能課税の立場を原則としていることは否定できない。その上、

応益原則からすると、税率は比例税率とすべきところ、現行法は法人につき原則として累進税率を採用しており、このことも現行法が応能課税の立場に立つことを裏付けるものである。」

判決は、後述のように、財政学的応益課税を否定しながら、この部分では応益課税＝比例税率、応能課税＝累進税率という財政学的図式を使っている。しかし、応益か応能かという議論は、結局のところ課税根拠の問題にすぎず、比例税率等の負担配分の問題が課税根拠と直結するわけではないし、仮に応益課税を根拠とするものがあつたとしても、受益に応じた累進課税はあり得ないわけではないことが無視されている。

以上のような前提の下で、判決は現行地方税法72条の19の解釈を展開する。まず、例外4業種が所得を課税標準としない理由を検討し、「これらの例外4業種について、その課税標準を定めるに当たっては、応能原則に基づいて所得を課税標準とすることにより適切な担税力の把握ができるか否かを検討し、当該事業の収益構造等の事業自体の客観的性格又は法律上特別の制度があることによって、所得を課税標準としたのでは適切な担税力の把握ができない場合に、外形標準を用いることとしたものということができる」とし、ここでも応益課税ではなく応能課税を強調し、「事業税の理想としての応益原則を課税を正当化する一つの要素として念頭に置きつつも、現実に存在している事業税は、例外4業種に対する外形標準課税の部分を含めて、すべからく応能原則を大原則とし、例外4業種以外の業種については、応能原則そのままに所得課税がされ、例外4業種についても、所得を課税標準とするものではないが、適正な担税力の指標として所得が十分に機能しないために所得に代わる担税力の指標として収入を課税標準とするものとして立法されたものと解すべきである」という。

ここにも、応能課税原則＝所得課税だという単純な図式が見えている。

このような前提からすると、「事業の情況」というのは相当限定されてくるが、判決はこの点につき、「ここでいう『事業の情況』とは、当該事業の収益構造や法律上の特別の制度の存在など当該事業が順調に行われていてもなお所得が担税力を適切に反映しないといった事業自体の客観的情況を意味するのであって、その時々々の景気状況や経営の巧拙に基づく業績状況といった事業自体の客観的性質に基づかない事態は含まれないものと解するのが相当である」ということになる。

そうすると銀行業の場合にそのような事情があるといえるかが問題となるが、「銀行業等については、所得を課税標準とした場合に事業の性質や法令上の制度の存在により適切な担税力の把握ができないことは何らうかがわれない。被告らは、銀行業においてはバブル期よりも大きな業務粗利益を上げていながら法人事業税をほとんど負担していない事態を『事業の情況』としているが、このような事態は、バブル崩壊という一時的な景気状況を直接のきっかけとして生じたものにすぎないし、原告らの中にも一部法人事業税を納めている銀行があることからもうかがえるように、個々の銀行のそれまでの業績の推移や経営者の手腕といった主観的事情によって左右されるものであって、銀行業自体が有する客観的情況とは到底いい難いものである。また、銀行業等の場合、貸倒れは必然的に伴うものであるから、貸倒損失分のリスクを見込んで貸出金利を高く設定することにより、客観的な事業の性格ないし構造として、事業存続のために十分な利益(所得)が得られようになっているものと認められ、貸倒損失を控除した所得こそがその担税力を示すものであって、この点では他の一般事業会社と異なるものではない。しかも、銀行業等については、一般には統一的な経理基準により適正な記帳がされ監査等も実施されているのであるから、所得を捕捉するのに困難があるとか、所得が適正に算出されていないとはいえないことも明らかである。したがって、銀行業等については、所得が当該事業の担税力を適切に反映するものであり、原則どおり所得を課税標準とすべきであ

って、この場合に外形標準課税をすることは許されないものというほかなく、銀行業等については、地方税法72条の19が外形標準課税を許す『事業の情況』があるものとは認められないのであって、本件条例は、同規定に反して違法であり、無効なものといわざるを得ない」と結論づけられている。

さらに判決は条例制定の任に当たった主税局の「過失」について次のような判断までしている。「本件条例は、地方税法72条の19に基づくものであるが、法的素養を有する者が同条とその引用する同法72条の12とを併せ読めば、同法72条の19にいう「事業の情況」とは、日常用語的な意味ではなく、例外4業種について例外的取扱いをする根拠となった事情に準ずるようなものに限定されるのではないかと疑義を抱くのが通常であると考えられる。そして、この『事業の情況』についての解釈を行う法律家としては、そのような疑義が生じた以上、上記両条を中心とする事業税の立法の沿革に遡って調査を遂げ、その調査結果を踏まえ、両条の立法趣旨を理解した上でなければ、上記「事業の情況」の意義を確定し得ないとの態度を取るのが、専門家として採るべき途であると考えられる。このような観点からすると、法律の専門家ではない被告東京都知事や都議会議員はともかくとして、都税に関する条例制定に関する事務を所管し、これらの者に的確な情報を提供すべき立場にある東京都主税局の担当者らは、その所管する地方税に関する法令の専門家として、上記のような調査を遂げて正確な情報を被告東京都知事及び都議会に提供すべき義務を有していたものと考えられる。しかし、本件全証拠によっても、このような調査に基づいて条例制定の可否が論じられた形跡はなく、本件における被告ら提出の証拠にも、前記両条制定時の国会議事録が含まれていないことからすると、これらの調査が全く行われなかったか、行われたとしてもきわめて不十分なものとどまったと認めざるを得ず、東京都主税局の担当者らには、この点において、十分な調査をせず被告東京都知事に的確な情報を伝えなかったことにつき、過失があったといわざるを得ない。特に、東京都主税局長は、都議会において、現行の事業税につき、所得課税という応能原則による課税が行われていることを認識しながら、あくまでこれが応益原則に基づくものと強弁し、かつ、銀行の業務粗利益が一般事業会社の売上総利益に相当するとの誤った説明を行い、都議会議員らの判断を誤らせるに至ったのであるから、これらについての過失が問われなければならない。すなわち、現に行われている事業税の課税が応能主義によっていることを認識している以上、上記アの疑問と相まって、本件条例のような課税が可能か否かには強い疑問を抱くべきであるにもかかわらず、法の明文に規定されていない応益原則によって本件条例が正当化されると考え、都議会においてもそのような説明をしたことは、所管局の責任者としては、ほとんど重過失に近い過失があったといわざるを得ない。」

本件で初めて「事業の情況」についての法的判断が下され、しかも、従来の一般的理解では本件のような厳格な解釈はなされていなかったにもかかわらず、本判決のように解するのが当然であり、その点を説明しなかったことに重過失に近い過失があるというのである。

三 判決の論理の問題点

(1) 応益課税＝所得課税なのか

判決は以上のように応能原則を強調している。実は、私も応能課税が憲法上の原則だと強調してきた立場なので、この点は同じなのであるが、だからこそこの判決には疑問があるのである。というのは、地裁判決は憲法上の原則は応能課税だから、事業税は所得税である、つまり、応能課税＝所得課税というきわめて短絡的な理解をしているからである。所得税は応能課税にもっともふさわしい税制であることは私も強調しているが、それは「所得」課税だからではない。所得課税

であっても物税的に構成して単純に「所得」そのものに課税するシステムが採用された場合、それが憲法の応能課税原則に反することもありうるのである。たとえば、高齢の両親や幼い子供を扶養しているAさんと独身のBさんが同額の所得を得れば同額の税負担になるようにすることも可能である。しかし、それではあまりにも負担の公平を歪めるので、扶養控除等の各種の人的控除を通じて納税者自身の人的負担能力を配慮しているのであり、それが所得税の応能化に貢献しているのである。法人税の場合は、会社が利益追求を目的とした社団であることから人的控除の余地がない。従って、各企業が有している負担能力をさしあたりは所得のみで測り、資本金による負担能力の差を税率面で配慮してきているのである(法人税法66条2項参照)。応能原則の実現過程で資本金等の所得以外の要素もその判断材料に含まれることはここからも理解されよう。

事業税の場合に、事業税の課税理念からみて望ましい応能負担をどう実現したらいいのだろうか。実は銀行税の目的も真の意味での応能化の実現だったのであり、これを訴訟で東京都が従来財政学でいわれてきた応益原則を強調したために揚げ足取りをされてしまったのである。事業税は一体何を課税根拠とし、その課税根拠からすれば何に担税力を見いだすのが適切なのか、等が本来きちんと検討されるべきであった。判決は事業税の変遷過程をおいながら、結局、「25年法が採用した応益的な考え方は、事業税の賦課を正当化する理由ないしは制度の理想として所管官庁において維持されていたものの、これをそのまま税制に反映させることは納税者の能力を超えるものであったことから、これを廃止せざるを得なくなり、現実の税制としては、納税者の能力に応じた所得課税を基本とする制度を維持せざるを得なかったものということができる」と認定している。東京都が考えている課税理念としての応益課税を当時の立法者は断念し、応能課税としての所得税を採用せざるを得なかった、というのである。しかし、収入金額を課税標準とする制度から所得を原則的課税標準とする方式が変わったことが「応益課税から応能課税への転換」と単純化していることが実に奇妙である。私からすれば、これは事業の負担能力をはかる基準として収入金額にすることから、原則として所得金額に変えただけの話である。収入金額を課税標準にしても税率の仕組み等の工夫で応能課税の要請にふさわしいものにすることも不可能ではないからである。税負担は課税標準と税率の総合作用であることがこの判決には欠落している(この点について、ドイツの連邦憲法裁判所の1995年6月22日のドイツ連邦憲法裁判所決定を参照)。

また、事業税を所得課税だと単純化しているが、その場合に現行法が事業税を所得計算に際して損金となることをどう説明するのだろうか。所得課税であれば、事業税は「所得」に税率をかけて求められるべきものだから所得計算過程で控除してはならないはずである。この点を、判決は「これらは、あくまで所得税法及び法人税法がそれぞれ所得税及び法人税の課税標準を算出するに当たって事業税をどのように扱うかという技術的な規定にすぎない」と断定している。事業税を所得課税であると理解すると論理的に説明できない現行地方税法の制度を「技術的なもの」に退けているのである。ご都合主義的理由付けといわざるをえない。

(2)「事業の情況」の限定解釈

事業税が所得税だとする判決の論理からすれば、所得以外の課税標準の採用を認める「事業の情況」は当然厳格なものになる。判決は、その基準として「該事業の収益構造や法律上の特別の制度の存在など当該事業が順調に行われていてもなお所得が担税力を適切に反映しないといった事業自体の客観的情況」と解している。しかし、例外4業種とほぼ同様の基準が必要であるというなら、そのような事情はなにも自治体が条令制定をするまでもなく地方税法の改正で対処しう

るものであろう。従って、自治体がこの条文から独自に条例を制定出来るのは、当該自治体内に例外4業種と同様な客観提起事情がある場合に限定される。このような業種を特定自治体内に見いだすことは現実的にはあり得ず、結局、地裁判決の判断に従うなら独自の課税をしようとする自治体はまず存在しないことになる。また、何よりも同条の規定からみて判決のような著しく限定した解釈は不合理だと思われる。なぜならば、地方税法第72条の19は「法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の状況に応じ、・・・所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる」としてしか規定していないからである。判決のような前提で立法されているならば「例外4業種以外の業種の課税標準についても、例外4業種と同様の事業の状況が認められ場合には・・・所得以外の課税標準を用いることができる」というような規定になっていたはずである。事業税の性格については、現行地方自治法の条文重視の解釈をしておきながら、例外規定となるととたんに目的解釈に転換している。ここでも地裁の判断は論理的ではないし、解釈方法も一貫していない。結論が先にある判断方法といつてよい。

(3) 過去の原因からの配当

判決は、事業税＝所得税と解するので、銀行側が配当を行っていたとしても、それが過年度の積立金を原資とするものであったことを強調し、従って、当該年度の所得がなかったとして次のように東京都を批判する。「仮に、銀行業に対して何らかの公的援助を行う場合には、このような配当の事実も援助の可否の決定に当たって考慮すべき事項であると考えられるが、これとは逆に新たな税負担を求める際には、このような事実は全く根拠にならないものというべきである。」

このような解釈は、事業税をあくまでも所得税と解するからであり、判決はその前提のもとで、配当がなされたことを意図的に強調し当該年度に所得があるかのような誤解を与えて立法させた東京都を批判している。しかし、立法に際しての判断資料の理解の問題であり、本県条例制定に反対する議員が問いただし、議論すべき問題であろう。しかも、このような配当の有無自体も決して「事業の状況」と無関係とはいえないのである。事業税の本質を事業自体の規模に担税力を見いだしたものである解する立場からは、過年度の積立金を原資にしているとはいえ配当できるということ自体事業の担税力をはかる一つの推計要素であり、「事業の状況」を判断する要素になりうるからであり、私見もそう考えてきているからである。

(4) 主税局長の過失？

本件条例の解釈論としては、確かに、二つの視点があり得るので、地裁判決のような論理も形式的にはあり得るとはいえよう。しかし、判決が、本件条例制定に際して主税局長が応能課税の趣旨を理解せずに議会に説明したことや、業務粗利益を課税標準にするに際してこのようなものが現行法上許されないものであることを通常人であれば容易に気づくはずなのに、これを誤った説明をしたことは重過失に近い過失があったと断定していることには驚かざるを得ない。本件条例が地方税法のもとで許されないことがすでに明白に確定しており、そのことを通常の立法関係者なら当然気づくべきものであったのであればともかく、初めての条例で、しかも今回初めての司法判断がなされて、さらにいえば学説も対立している中で、一方の解釈方法以外の判断を重過失に近い

過失と断定するのは、司法判断としてはあまりにも踏み込みすぎており、危険である。仮に、高裁判決で本件条例の適法性が認定された場合、ここまで断言した裁判官自身の常識が問われることになってしまうのではないだろうか。

おわりに

なお、判決は東京都が本件条例を適法と解した根拠に、その適法性を唱える学者の数が違法性を唱える学者の数に比して圧倒的に少数であることを指摘し、適法性を根拠づけるものではないとしている。判例が常に学界の多数説を採用しているとでもいうのであろうか。

なお、私見は銀行税条例が違法とはいえないとは解しているが、今回の銀行税条例制定過程に問題がなかったと考えているわけでもない。新たな税負担を求めるには、やはり負担者にもある程度納得されるような慎重な制定手続きが求められることはいうまでもない。その点を、もう少し適切に行っていれば、このような訴訟事態を回避できたかもしれないといえよう。その意味で、今後の条例制定に当たっては地裁判決の批判等は東京都としても十分に留意する必要があることはいうまでもないであろう。

平成13年12月12日

意見書（再論）

東京地方裁判所民事3部御中

立命館大学法学部教授
三木 義一

はじめに

筆者は平成13年11月7日に本件「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」(以下「本件条例」という)の適法性を論証するために意見書(以下「拙稿」という)を提出したが、これに対して原告側は第8準備書面において品性と論理的根拠を欠いた非難を投げかけている。その反論内容のあまりの稚拙さに一税法研究者として驚かざるを得ないが、その稚拙さを明確にし、原告側の主張が本件条例の意義及び地方税法の解釈を誤ったものであることを再度明らかにしておきたい。

一 支離滅裂

原告側は拙稿が「結論が先にある意見書と言ってよく、それを導くための理由は支離滅裂である」(第8準備書面41頁)と非難する。しかし、拙稿が支離滅裂な主張をしている

ことの具体的な論証はなく、非難の言葉だけを投げかけるという法的論争方法として恥ずべき記述となっている。一般に「支離滅裂」というのは「統一がなくばらばらに乱れて、筋道が立たないさま」(広辞苑)を意味しており、これを原告の主張に即して言うならば次のようになる。

原告は「三木意見書は、あたかも原告らが『事業税は「所得税」ないし「所得課税」である』と主張しているとの前提において、『原告の主張のほとんどが根拠を失う』と述べている。これは、原告らが主張していない立論を意見書の基礎としており、意見書の基礎において根本的な誤りがあると」と批判している(第8準備書面66頁)。しかし、その同じ意見書の数頁前で「現行の事業税が、所得課税であることは、次のような見解からも明らかである」(同40頁)と主張し、さらに、原告第2準備書面では「現行の地方税が、抽象的な事業税の性格をどのように解するとしても、実際には納税者の担税力を配慮して、課税標準を『所得』とし、…『応能原則』を採用したものであることは否定できないことを意味している」(11頁)と主張しているのである。所得課税であると主張し、課税標準が「所得」(これは所得税そのものであろう)であることを強調しておいて、「原告らが主張していない立論を意見書の基礎としており、意見書の基礎において根本的な誤りがあると」と非難するような場合を、言葉の正しい意味での支離滅裂というのである。

したがって、「三木意見書は、原告らの主張書面及び提出証拠を与えられずに執筆されたのかその理由は明らかでないが、原告らが主張していない論旨を三木意見書がいくら批判してもそれは無意味である」(第8準備書面67頁)という無意味な批判をする前に、準備書面執筆者同士のきちんとした打ち合わせと、自己の書いたことの再度の点検をすべきであろう。

二 事業の背後にある担税力のスクリーンとしての所得

原告側は、第8準備書面で被告の主張及び拙稿の指摘を受けて、事業税が事業の背後に担税力を求める税であることを明確に認めはじめている(原告第8準備書面67頁)。したがって、現行地方税法が事業税の課税標準として暫定的に所得を借用しているが、所得そのものに課税するのではなく、所得というスクリーンを通じて推定される事業に課税していることになる。このことを理解しているのであれば、被告の主張及び拙稿を理解するのは容易であろう。地方税法の規定からしても、所得というスクリーンと事業の担税力とが相応していれば、所得を課税標準として事業税を課すことは何ら問題ないのであり、通常はこの課税標準に基づいて課税されているのである。問題なのは、所得というスクリーンでは事業の担税力と適切に表現できなくなった場合であり、事業税が所得課税するのではなく、所得というスクリーンを通じて事業に課税していることを認めるならば、その場合には、所得以外のより適切な基準で課税をすることを法は要求していることになるはずである。これを、原告は事業の背後に担税力があることを認めながら、いつのまにか「所得を基準に担税力をはかることを原則としている」(68頁)等と言い換え、事業税が所得課税であるかのように論旨をすり替え、所得以外の基準で課税できる余地をできるだけ狭めようとしている。しかし、原告が「事業税は所得税や所得課税ではない」というなら、論理は逆であり、所得以外の基準で課税する余地を広く認めねばならないはずである。

三 原告は、拙稿が「事業そのものに経済的価値を認め」と記述し、それが理解不可能な日本語であると批判するとともに、しかも、拙稿が「担税力をどのような基準で見いだすかについて何も示しておらず、むしろ何も示すことはできないと理解される」と批判している（第8準備書面69頁）。いったい、原告は拙稿を読んだのだろうか。拙稿のこの部分は、事業税が所得課税ではないことの根拠として旧自治省関係者の事業税の解説を引用した部分であり、日本語として理解不能なら当該執筆者に言っていただきたいが、事業税が所得課税でないことは読みとれよう。また、拙稿は、事業税の法的性格や担税力について、「事業税は、事業規模に応じた応益税というか、それとも現実の所得ではなく事業規模から推定される期待収益に着目した応能税でもあると解するか（筆者はそう考えている）はともかく、このように事業規模に着目した税であり、現実の所得そのものに着目したのではない」（拙稿＊頁）と、自己の意見は明確にしているのである。

また、原告は、拙稿が「所得を課税標準とすることは整合性を欠くから、現行法も所得を利用しつつ、所得課税的でないような工夫を地方税法はおこない、それでもだめなら外形標準課税を選択するという構造になっている」という論旨を展開し、「全くもって不可解」と批判している（69頁）が、筆者にもこの論旨は全く不可解である。なぜなら、原告は拙稿を勝手に読み替え、勝手に主張を省略し、全く意味不明の文章にしているからである。拙稿のこの部分は正しくは次のように主張されているのである。「**したがって、事業税はその課税根拠からして「所得」を課税標準にするのは論理的に整合性を欠き、現行法も「所得」を利用しつつも、純然たる所得そのものではなく、各種の加算・減算規定を設け（法72条の14、72条の17、同法施行令21条～21条の7等参照）、事業規模を少しでも反映できるように配慮し、また所得で課税するのが法制度上等の理由から明らかに不合理である事業について「収入金額」を課税標準にすることを明記し（法72条の12）、さらに様々な理由から所得課税が不合理になる場合があることに備えて「事業の状況に応じて」（法72条の19）所得以外の課税標準を選択する余地を明記してきたのである。**」

この主張のどこが不可解なのだろう。自分で勝手に誤った省略をし、その結果意味不明になり、それを根拠に相手を非難するという、論争の初歩的ルールすら守れないお粗末な批判である。

四 一般規定と特例規定

拙稿は、不均一課税と本件特例の関係につき、原告が地方税法の基本的な解釈を誤ったものであることを次のように具体的に指摘した。

「原告側の解釈で奇妙なのは、本件に地方税法6条2項の不均一課税の規定を適用し、本県条例が同規定違反であることを強調していることである。同規定は、いうまでもなく、地方税全税目について不均一な課税を認める要件を規定したものであり、全税目を対象とした一般規定である。この一般規定に基づく不均一課税は、あくまでも地方税法上の各税目に対する特例規定がない場合に適用されるのものであり、同時に、地方税法は各税目のそれぞれの趣旨に相応しい多くの特例規定も設けているのである。しかも、このような特例規定は不均一な課税を結果としてもたすが、当該税目に関わる具体的必要性から設け

られているので、当該特例の要件に該当すれば一般規定の要件を問題にすることなく違法の問題は生じないのである。これを原告のように解すると、例えば固定資産税における新設大規模償却資産の課税標準の特例（地方税法349条の5）等も不均一課税をもたらすので、地方税法6条2項の適用となり、当該不均一課税は特定の資産の固定資産税を不均一に重課するので違法ということになり、地方税法が特例規定を設けた意味は全く失なわれてしまうのである。このように、一般規定と特別規定の関係を混同した解釈を原告側が縷々展開しているため、議論が一層混乱している。本件条例はあくまでも地方税法自体が規定している72条の19の特例に基づき定められたものであり、したがって、本件条例の適法性は当該特別規定の要件を充足しているかどうかで判断されるべきものなのである。原告側のように、本件条例を特例規定と一般規定である地方税法6条2項にも適合していなければならないとすると、本件特例規定で定められているガス供給業者に対する課税標準の特例も事業者のうち特定業種に対する不均一課税をもたらすので、地方税法6条2項が適用され、その結果、不均一に重課する結果となるので違法という奇妙な結果になる」

これに対して、原告は、いろいろ反論しているが、これが全くの論理矛盾であることをまだ自覚していないようなので、少し整理しておこう。

原告は、拙稿の指摘に対して「不均一課税については、全部の銀行業等に導入しないことについて問題にしているにすぎない」（48）とか「地方税法の『特例規定』を受けて、他の業種とは不均一課税状態が法律の特例規定レベルで発生しているとしても、ガス事業者全体に不均一でない課税を行う条例を制定するのは、地方税法でいる不均一課税ではないと考えてきたからである」（70）と述べている。要するに、特定事業が不均一に課税されても当該特定事業全体が不均一に課税されているなら、不均一課税にはならないというのである。この場合に、不均一なのになぜ不均一課税の規制に服さないかというのと、その根拠は特例規定の要件を満たしているからと言うことになる。結局、ここでは特例規定の要件を問題するだけになる。

次に、原告は「特例規定どおりの規定を条例で定めるとともに、この条例制定段階で初めて不均一課税を行う場合（ガス事業者の事業規模に応じて不均一課税を行うような場合である。）に地方税法6条2項の要件が充足されていなければいけないと述べているにすぎないのである」（49）とか「特例規定を受けて条例を制定する場合に、当該特例の法律段階には書かれていない不均一課税をすることを条例で行う場合に不均一課税規定を考慮しなければならないとすることが、なぜ趣旨を失うことになるのか」（71）、等々と反論している。原告の主張は、要するに、銀行業全体やガス事業全体に特例を適用するのは許されるが、その一部のみの特例を適用すると不均一課税となり、許されないという主張のようである。しかし、特例が事業全体に適用することを求めているのに、その一部のみに適用するのは不均一を持ち出すまでもなく特例違反と言うことになるはずであるし、逆に、業者の一部に特例を適用することが許されるのであれば、特例適用の要件を満たしている以上不均一課税は問題にならないことになる。要するに、特例適用要件の解釈問題にすぎないのである。

一方、原告の主張は極めて奇妙な主張になる。抽象的に書くと理解できないようなので、原告側が示した例でわかりやすく示すと、原告は「ガス事業についての外形課税についての特例に基づいて、条例にガス事業につき外形課税を行う旨の規定を置く」ことは許され

るとし、「条例制定段階で初めて不均一課税を行う（ガス事業者の事業規模に応じて不均一課税を行うような場合）」こと、本件の場合に即して言えば、ガス事業者の一部に外形標準を適用するのは条例段階で不均一課税を行うことになり許されない、というのである。この場合に想定される条例内容は、次のようになる。

第1条 ガス事業（全体）に対しては外形課税を行う。

第2条 ガス事業のうち資本金5兆円以上の事業に対しては外形課税を行う。

このような論理矛盾をきたしている条例は、不均一課税を持ち出すまでもなく、どちらかの適用要件が誤っているのである。

ひょっとすると、原告は、本件特例適用の問題と税率の問題を混同してしまったのかもしれない。というのは、原告の主張に即してありうべき事例を想定してみると、銀行業全体に対して外形標準を適用し（業者全体だから許されると原告はいう）、しかる後に、銀行業の一部に対して同じ外形標準に基づきながら差別的税率を適用するような場合も考え得るからである。理論的には面白い問題だが、本件条例とは関係ないレベルの問題である。

四 事業の状況

原告は、拙稿が「原告主張のように、法制度上の制約がある場合等に限定するなら、何も自治体の判断に委ねずに国自体が法制度制定に際して地方税法の改正による特例追加で十分に対応できる事柄であり、本件特例規定はその存在意義を失ってしまうのである」と指摘した点につき、「これは批判とはなっていない。原告らは、上述のとおり、『法制度上の制約がある場合に』限っているのではなく、『恒久的な構造的特徴がある場合』をも掲げているのである。ところが、三木意見書はこの後者を批判できていない」と反論している。この反論も拙稿を読んだうえで反論しているとは思えない。拙稿は「原告側の主張の特色は、まず第1に、本件特例を適用できる要件は、『例外4業種の場合と同様に、所得基準では恒常的に税収が確保できないという点について制度的な特別な理由ないし恒久的な構造的特徴がある場合に限って充足されると解されるべき』だとしている点にある」（*頁）と原告の主張を正確に示した上で、「しかし、この解釈は地方自治法の特例規定の意義を見失った解釈である。現行法は、国の法制度等により所得を課税標準にする事が適切でない4業種について所得以外の課税標準を明記したが、事業税の前述の性格からして所得を課税標準にするのが適切でない場合があり得るので、各自治体が不適切な状況を的確に判断して特例を適用し得るように『事業の状況』に応じた課税標準の選択の余地を認めているのである。これを、原告主張のように、**法制度上の制約がある場合等**に限定するなら、何も自治体の判断に委ねずに国自体が法制度制定に際して地方税法の改正による特例追加で十分に対応できる事柄であり、本件特例規定はその存在意義を失ってしまうのである」と批判しているのであり、後半の「法制度上の制約がある場合等」には当然に「恒久的な構造的な特徴」も含まれるのであり、この両者を批判しているのである。また、原告は「恒久的な構造的な特徴」は金子教授の見解の引用であるというが、原告が指摘する部分には（第8準備書面が引用する第2準備書面30頁には『租税法』第8版379頁～80頁とある）がそのような記述は存在していない（添付資料参照）。そもそも原告が資料として提出している甲6号証にもそのような記述は全くない。いったい、この代理人は人を批判するときの論拠をきちんと検証しているのだろうか。このような初歩的な検証も怠った上で、拙稿

を「専門家として鑑定意見とは到底みなされないほど偏向している」と非難しているのである。この部分を執筆した代理人は、法律家として恥を知るべきである。

五 所得課税との均衡、その他

原告は、所得課税の均衡の問題につき、『『単年での比較を想定していたと考えるのが適切な解釈である』との原告の主張が碓井教授の鑑定意見書に立脚しているところを無視し、結論のみ批判している点で、批判の論拠を完全に欠落している」と反論している。この批判の趣旨は一体何なのだろう。拙稿は、原告側が引用している碓井意見書等を具体的に踏まえて、単年度で比較すべきという原告の主張は「極めて不可解である」と指摘し、その論拠として「仮に、この主張が、ある年度の現実の所得金額を課税標準とした場合と比較した当該年度の外形標準課税の負担が均衡を失してはならない、という意味なら、外形標準課税の存在理由はなくなってしまうからである。外形標準で課税するのは、各業種で算定される現実の所得では当該事業の担税力を適切に表せないと判断されたからこそであり、この場合の税収が現実の所得に課税した場合と差がでないようにしなければならないのであれば、外形標準課税を導入する意義が全く失われてしまうことは明らかであろう」と指摘しているのである。しかも、原告側が引用している碓井教授の意見については、同じ引用するなら「もっとも、所得を標準とする場合と外形標準の場合とでは、個々の納税者について負担が異なるのは当然であって、例えば、欠損法人の場合、前者では負担零であるのに、収入基準を採用すると相当な租税負担を負うことになる。このような状態には、税率についての右制限規定（法72条22第9項）があてはまらないものと解釈しなければならない」（甲102号証。碓井光明『地方税条例』（学陽書房、昭和54年）65頁）という箇所を引用した方がはるかに明快である、とも指摘しているのである。これがどうして批判の論拠を欠いているのか論証していただきたい。

拙稿が指摘したように、「この『均衡』は当該事情の現実の所得ではなく、当該事業における通常あるべき所得との対比において検討されるべきもの」なのであり、その場合には原告主張のように単年度だけのデータで課税するのはかえって恣意的になる虞があることはあきらかである。したがって、被告が行ったように複数年度のデータに基づいて負担水準を決めたのは、原告の主張とは逆に、恣意的にならないように配慮した適切なものだったのである。

その他は、言葉尻の一部だけをとりえて非難するだけで、何ら拙稿の指摘した法的内容に反論できていないものなので、ここでいちいち取り上げない。

六 原告の拙稿に対する批判は、以上述べてきたように、法的論争としてはあまりにも低レベルでいちいち反論する必要もないかもしれない。しかし、原告の反論だけを読んだ者には筆者に対する著しい誤解が生じる虞があるのであえて反論し、近似税務訴訟において従来とは異なる公正な判断を示している東京地裁の藤山コートに注目している一税法研究者として、拙稿の趣旨を再度明らかにさせていただいた。

意 見 書

東京地方裁判所民事 3 部御中

立命館大学法学部教授
三木 義一

はじめに

本鑑定意見書は、「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」（以下「本件条例」という）に関する「東京都外形標準税条例無効等確認請求事件」の争点のうち、地方税法違反を中心とする実体税法上の争点について、私見をまとめたものである。

本件争点をめぐる被告・原告の主張をみると、双方とも必ずしも争点が整理されておらず、いたずらに無用な議論がなされている感があり、特に原告側の主張は地方税法（以下「法」という）の体系的な解釈及び事業税の法的性格からしてあまりにも不合理な主張が多く、地方自治及び地方税制度の趣旨を損なう虞もある。そこで、できるだけ実体法上の争点をわかりやすく整理しながら、私見を述べてみたい（なお、筆者は「外形標準課税と訴訟の論点」都市問題2000年10月号49頁以下において、本県条例の争点について基本的な考え方を述べているので、できるだけ重複を避けながら、原告の主張の不合理さを詳細に論じることにはしたい）。

一 事業税の法的性格

本件の争点に関する原告・被告の主張をみてみると、あまり生産的とは思われない「応能課税」「応益課税」かの議論に多くの紙数がさかれている。事業税に応益課税が妥当するのか、応能課税が妥当するのかはともかく、まず確認しなければならないのは、事業税は「所得」課税ではない、という点である。なぜならば、もし事業税が原告主張のような「所得」税であれば、何よりも現行の道府県民税と抵触し、同一の課税団体が同一の課税標準に二重の課税をすることになってしまうし、仮に、事業「所得」に特別の担税力があると考えらるなら、事業所得部分の税率を道府県民税の枠内で調整すればすむことである。しかし、現行地方税は「所得」を課税客体とする道府県民税とは別個に独立した税制として定めている。それは、事業税は本来的に「所得」税ではなく、所得税とは異なる課税目的のために、所得税とは異なる課税客体に着目して制定されたからである。このことは、原告・被告双方が指摘している事業税の沿革からみても明らかである。そうであるからこそ、旧自治省関係者の事業税に関する解説では、「事業税の課税客体は事業である。課税客体とは、そこに担税力を推定し、租税の課税対象として定められる物件である。すなわち、事業税は、事業そのものに経済的価値を認め、そこに担税力を見だし、課税するものである」（前川尚美・臼井守・小川徳治『地方税〔各論Ⅰ〕ぎょうせい・昭和53年』247～8頁）とか、「事業税は事業を行うという事実に着目して、事業そのものを課税客体とし、事業の規模ないし活動に応じて課する性格の税である」（松尾徹人・小林弘明・折笠竹千代『自治行政講座・第10巻・地方税Ⅰ』第1法規、昭和61年、452頁）等々と説明されてきたのである。したがって、事業税はその課税根拠からして「所得」を課税標準にするの

は論理的に整合性を欠き、現行法も「所得」を利用しつつも、純然たる所得そのものではなく、各種の加算・減算規定を設け（法 7 2 条の 1 4、7 2 条の 1 7、同法施行令 2 1 条～2 1 条の 7 等参照）、事業規模を少しでも反映できるように配慮し、また所得で課税するのが法制度上等の理由から明らかに不合理である事業について「収入金額」を課税標準にすることを明記し（法 7 2 条の 1 2）、さらに様々な理由から所得課税が不合理になる場合があることに備えて「事業の状況に応じて」（法 7 2 条の 1 9）所得以外の課税標準を選択する余地を明記してきたのである。

以上の点は、地方税としての事業税の大前提で、この前提を肯定すると原告の主張のほとんどが根拠を失うために、原告側は何とか「所得」課税であることを印象づけようとし、相当強引な解釈をしている。例えば、原告は、事業税が「所得」税であり、「応能原則」に基づくものであることの論拠として、旧自治省府県税課の「現行法上、大部分の事業について所得を課税標準にしているのは、事業を行う者にとって所得が少ない（あるいは無い）のにかなりの税負担をすることが酷に感じられる可能性があること、税務行政の簡素化を図ること等を配慮したためと考えられる」という解説を引用している（原告準備書面 2・1 1～1 2 頁）。どうしてこれが所得課税・応能課税の論拠になるのか理解に苦しむ。同解説は、事業税の性格からすれば事業規模に相応しい外形で課税するのが望ましいが、そうすると所得が少ない事業者にとっては負担が酷になることや、事業に相応しい外形標準を定めることは行政にとっても手間がかかるので便宜的に所得を利用している、という趣旨に他ならないのであり、全く逆の説明だからである。この点は被告第 6 準備書面 6 頁が指摘するとおりである。

いずれにせよ、原告側の意見書を書いた碓井教授自身も「しばしば誤解されているようであるが、現行地方税法自体が外形標準課税を許容していることを強調しておかなければならない」（『地方税条例』学陽書房昭和 5 4 年 6 5 頁）と指摘しているように、事業税の法的性格を素直に実定法に則して解すれば、課税標準を事業規模から推定される担税力を適切に把握しうるものにする方がより望ましいと解され、その方向が従来から模索されてきたのである。

このことは旧自治省関係者の次のような指摘からも容易に確認されよう。

「事業税は物税であり、一方、道府県の公共サービス提供に対する一種の受益者負担的性格を有するものである。このことから、企業の収益如何にかかわらず、企業規模に応じた税負担が望ましいことが考えられる。もっとも、税は最初にその性格が定められ、次のそれに適合した課税標準を決定するという順序で形成されるものではなく、第 1 款（沿革）でみるとおり、財政上の理由、経済の状況、財政政策等を背景とし、長い経過をたどって現在の課税標準が定められているものである。事業税が、法人の特定の業種を除いて、所得を課税標準としているのは、その税の性格から決定されたものではなく、以上のような沿革に起因している。したがって、事業税の性格から、あるべき型を考える場合、すなわち、物税、受益者負担等を具現するためには、どのような型が望ましいかを考える場合に、所得のみを課税標準とすることは必ずしも適当なものではないといえよう。このことは欠損を生じた場合には、物税たる事業税の負担が零になることを考えれば、所得以外の企業規模に応じた税負担を求めることが指向される。」（前川尚美・臼井守・小川徳治・前掲書 2 5 0 頁）

「このような事業税の性格からするならば、事業税の課税標準としては、当然事業の規模ないし活動量を表すものがとられるべきであり、また、地方税の安定的確保の観点からも望まれるところである」(松尾等・前掲書452頁)

事業税は、事業規模に応じた応益税というか、それとも現実の所得ではなく事業規模から推定される期待収益に着目した応能税でもあると解するか(筆者はそう考えている)はともかく、このように事業規模に着目した税であり、現実の所得そのものに着目したものではない。諸外国における営業税も同様の理由で導入されている(例えば、ドイツ場合、Micael Daumke, Grundriß des deutschen Steuerrechts, 4 Aufl., 1999, S. 276 によれば、つぎのように説明されている。「事業税は物税、すなわち、租税との接点(課税対象)が所得税のように人の個人収入ではなく、『事業(Gewerbebetrieb)』それ自体である。それゆえ、事業税は物税とも呼ばれる(租税基本法3条2項)。事業から事業税を市町村税として徴収するという権限が市町村に認められている理由は、伝統的に見れば、事業による直接および間接の負担が、市町村に生じていることによるものである。したがって、原告のように、72条の19の課税標準規定を例外規定と解し、厳格に限定解釈するのは、事業税制定趣旨及び現行の地方税法の体系に反した解釈であり、むしろ、所得を課税標準とする場合より事業規模を適切に反映できる課税標準を広く許容する規定と解するのが、地方税法の趣旨に相応しいといわねばならない。

原告の主張は、この前提を見誤っている点に最大の問題があり、このことと様々な不合理な主張が連動しているのである。例えば、『業務粗利益』は、不良債権処理にかかる損失額が勘案されていない勘定科目であり、これを課税標準として課税するのでは、不良債権処理の促進という法の趣旨とも明らかに矛盾する(戸松意見書9頁)とか、「貸倒の可能性を軽視して銀行に対する課税を行っている」(中里実「最近の地方団体の新税案について」税2001年17頁)、「不良債権処理の法的意義を無視するに等しい銀行税条例」(平成13年9月14日付首藤意見書9頁)等々の指摘があるが、これらはいずれも事業税が「所得」税であることを前提にした批判にすぎず、こうした債権処理の要請は「所得」税制である道府県民税等の中に反映されているのであり、事業税はそれとは異質な事業規模に担税力を見だしている税制であることを見落としてはならないのである。この基本的な視点さえ理解できていれば、むしろ、債権処理政策により「所得」金額では事業規模を適切に反映しなくなった以上、自治体は積極的に「事業の状況」を適切に反映した課税標準を選択すべきであり、それが地方税法の趣旨だということがわかるはずである。さらにいえば、株式の評価損や評価益等々の事業規模とは直接の関係ない要因により「所得」金額が事業規模を反映し難くなった場合等も、より適切な課税標準を選択することが求められよう。いずれにせよ、原告主張のように、所得課税以外の税制にまで債権処理法制との連動が必要というなら、こうした債権処理を全く配慮せず、評価額を引き上げてきた固定資産税も債権処理法の趣旨に反することになるが、その不合理さは明らかであろう。その意味で、原告の主張の大半は、その前提を誤った、的はずれの議論といわざるを得ないのである。

二 一般規定としての不均一課税と本件

第2に、原告側の解釈で奇妙なのは、本件に地方税法6条2項の不均一課税の規定を適用し、本県条例が同規定違反であることを強調していることである。同規定は、いうまでもなく、地方税全税目について不均一な課税を認める要件を規定したものであり、全税目を対象とした一般規定である。この一般規定に基づく不均一課税は、あくまでも地方税法上の各税目に対する特例規定がない場合に適用されるのものであり、同時に、地方税法は各税目のそれぞれの趣旨に相応しい多くの特例規定も設けているのである。しかも、このような特例規定は不均一な課税を結果としてもたすが、当該税目に関わる具体的必要性から設けられているので、当該特例の要件に該当すれば一般規定の要件を問題にすることなく違法の問題は生じないのである。これを原告のように解すると、例えば固定資産税における新設大規模償却資産の課税標準の特例（地方税法349条の5）等も不均一課税をもたらすので、地方税法6条2項の適用となり、当該不均一課税は特定の資産の固定資産税を不均一に重課するので違法ということになり、地方税法が特例規定を設けた意味は全く失われてしまうのである。このように、一般規定と特別規定の関係を混同した解釈を原告側が縷々展開しているため、議論が一層混乱している。本件条例はあくまでも地方税法自体が規定している72条の19の特例に基づき定められたものであり、したがって、本件条例の適法性は当該特別規定の要件を充足しているかどうかで判断されるべきものである。原告側のように、本件条例を特例規定と一般規定である地方税法6条2項にも適合していなければならないとすると、本件特例規定で定められているガス供給業者に対する課税標準の特例も事業者のうち特定業種に対する不均一課税をもたらすので、地方税法6条2項が適用され、その結果、不均一に重課する結果となるので違法という奇妙な結果になる。あるいは、原告は、本件条例が特定業種全体ではなく、銀行業のうち一定のものに限定しているので、不均一を問題にするのだというのかもしれないが、本件特例には業種全体を一律にしなければならない要件は規定されていないし、後述のような同規定の沿革からしても到底相容れない解釈である。

このように、原告側の解釈は一般規定と特例規定を混同した解釈であり、このような解釈では地方税法が各税目に対して様々な特例規定を設けている趣旨が失われてしまうことから明らかなように、地方税法の解釈としては極めて不適切である。なお、原告側の意見書には、筆者が「立法技術的には、納税義務者を銀行業全体にし、中小企業への配慮から資金量5兆円以下の銀行業は免除するような方法の方が無難であったと思われる」と述べていることをもって、法6条2項に関連した指摘だと判断されているものがみられるが（平成13年7月16日付首藤意見書8頁）、前述のように、筆者はそのような非体系的な解釈は前提としていない。むしろ、筆者は本件条例に関連して上記のような誤った解釈をされる可能性や後述の課税対象の限定に対する批判が予想されることから留意的に記載したにすぎないのである。

三 「事業の状況」と本件条例

従って、本件の争点は、本件条例が事業税における特例の要件である「事業の状況」を適切に配慮した合理的なものであるか否かである。原告側は、前述のように事業税を「所

得」課税であるとする誤った前提に立った上で、「所得」以外の課税標準を認める「事業の状況」は厳格に解すべきだとしている（原告第2準備書面準備書面20頁以下及び30頁以下参照）。

この原告側の主張が、いかに不合理なものであるかを少し具体的に論じておこう。原告側の主張の特色は、まず第1に、本件特例を適用できる要件は、「例外4業種の場合と同様に、所得基準では恒常的に税収が確保できないという点について制度的な特別な理由ないし恒久的な構造的特徴がある場合に限って充足されると解されるべき」だとしている点にある（原告第2準備書面31頁）。しかし、この解釈は地方自治法の特例規定の意義を見失った解釈である。現行法は、国の法制度等により所得を課税標準にする事が適切でない4業種について所得以外の課税標準を明記したが、事業税の前述の性格からして所得を課税標準にするのが適切でない場合があり得るので、各自治体が不適切な状況を的確に判断して特例を適用し得るように「事業の状況」に応じた課税標準の選択の余地を認めているのである。これを、原告主張のように、法制度上の制約がある場合等に限定するなら、何も自治体の判断に委ねずに国自体が法制度制定に際して地方税法の改正による特例追加で十分に対応できる事柄であり、本件特例規定はその存在意義を失ってしまうのである。従って、地方税法がわざわざ設けた「事業の状況」は、原告が主張するような法制度上等から生じるきわめて特殊な事情に限定する必要はなく、国レベルだけではなく、各自治体における特殊事情をも含めて、「所得で課税するとかえって不公平になる事情」を広く含む概念であるといわねばならないのである。

原告側の主張の特色の第2は、「事業の状況」に応じた特例を「特定の事業」のみに適用したり、ましてや「特定の業種の一部」に適用することは許されない、と解していることである（原告第2準備書面20頁以下）。こう解しないと、不均一課税と繋がらないとためであろうが、現行法の規定からどうしてこのように読めるのか全く不可解である。なによりもまず、条文自体が「事業の状況」としか規定しておらず、「4業種以外の全事業者の事情」や「特定業種全体の事情」の存在を求めているのではない。また、現実問題としても、業者間で様々な事情の違いはあるし、同一業種間でも「事業の状況」が異なり、例えば、仕入れの形態や販売形態等からして所得では事業規模を適切に反映し得ない場合もあり得るのである。また、事業税の沿革からすると、原告指摘のように「営業ノ種類ヲ限り」から「事業の状況に」に変遷してきているが、これを原告のように「わざわざ上記文言が削除され法文上の表現が変えられていることからすれば、逆に外形課税を導入するに当たっては、全業種を一括して対象としなければならないことを念頭に置いていたと考えられる」（原告第2準備書面21頁）と解するのはどうてい無理であろう。なぜならば、厳格な要件からより抽象的な要件に変えられた場合、通常は当該適用要件が広げられたと解すべきなのであり、本件の場合も従来のように「営業ノ種類ヲ限り」に特例適用を限定していたのを「事業の状況」という抽象度の高い要件に変更して、従来同様営業の種類を限定した特例適用の可能性も認めた上で、「営業の種類」を限らず広く業者一般、あるいは業種の一部、さらには営業の種類以外の基準でも特例適用が可能になるようにしたのであり、その意味で自治体の合理的な判断の余地を広げたものに他ならないからである。原告の解釈によれば、昭和22年の改正は、全業種一括というより困難で厳格な適用基準に変更し、自治体の判断の余地を狭めた改正ということになるが、このような解釈は条文上も歴史的経

緯からしても誤りであるといわねばならない。

こうした点を総合すると、外形標準を許す「事業の状況」という要件は、事業税の本質との関係からみても、前述のように「所得で課税するとかえって不公平になる事情を広く含む」ものである。本件の場合、銀行業は、所得計算上は赤字であっても事業規模を測る一つの有力な基準である業務粗利益自体は多額にあり、かつ、バブル期以上に増えており、しかも、株主に配当できるだけの余力を有していながら、不良債権処理政策により「所得」金額が著しく減少したために、事業規模に応じた公平な課税は実現できなくなっていたのである。特に資金量5兆円以上の銀行業において従来との負担格差が著しかったという(被告答弁書第4の2以下参照)。このような場合、資金量5兆円以上の銀行については「所得以外の基準で事業税を求めるだけの事業の状況」が存在しているといわねばならない。

なお、公平論を主張するならば、銀行の融資を受けるために赤字にできず、そのため経営者自身の報酬をきわめて低額にし、ましてや配当などの余力もない中小企業でも、所得基準に基づき事業税を負担していることとの公平も考えねばなるまい。その意味で、本件条例が不合理などとは到底いえるものではないであろう。

四 所得課税との均衡

次に、地方税法72条の22第9項では外形標準課税が通常の所得等による課税の場合に比して「著しく均衡を失することのないようにしなければならない」と規定しており、同規定と本件条例の整合性が問題とされている。原告側はこの点につき「単年での比較を想定していたと考えるのが適切である」(原告第2準備書面34頁)という主張を展開しているが、極めて不可解である。というのは、仮に、この主張が、ある年度の現実の所得金額を課税標準とした場合と比較した当該年度の外形標準課税の負担が均衡を失してはならない、という意味なら、外形標準課税の存在理由はなくなってしまうからである。外形標準で課税するのは、各業種で算定される現実の所得では当該事業の担税力を適切に表せないと判断されたからこそであり、この場合の税収が現実の所得に課税した場合と差がでないようにしなければならないのであれば、外形標準課税を導入する意義が全く失われてしまうことは明らかであろう。したがって、この「均衡」は当該事情の現実の所得ではなく、当該事業における通常あるべき所得との対比において検討されるべきものであろう。銀行業における通常あるべき所得を、被告は、過去15年間の税収実績を勘案して推計し、その場合の負担と均衡を失しないように外形標準の税率を定めており、したがって、所得で課税する場合との均衡を失しているとは到底いえないであろう。また、原告側がある論者の論文を引用して「赤字法人の場合でも租税負担総額の負担の均衡と解すれば、単年度の均衡としても何ら問題ないとしている」と主張するが、全く意味不明である。むしろ、原告が意識的にはずした部分、すなわち「もっとも、所得を標準とする場合と外形標準の場合とでは、個々の納税者について負担が異なるのは当然であって、例えば、欠損法人の場合、前者では負担零であるのに、収入基準を採用すると相当な租税負担を負うことになる。このような状態には、税率についての右制限規定(法72条22第9項)があてはまらないものと解釈しなければならない」(甲102号証。碓井光明『地方税条例』(学陽書房、

昭和54年) 65頁) という主張の方がはるかに明快である。この主張によれば、原告主張とは逆に、銀行業が赤字であっても当該年度の事業税の負担を求められ、しかも、法72条の2第9項の制限規定は適用されないということになるはずである。

なお、当初原告側は、銀行側がこれまで多額の納税実績があり、東京都の業務粗利益×3%を基準にすると過去20年間で3800億円もの支払い超過があると批判していたが(平成12年3月付全国銀行協会「都の答弁説明に対する7つの疑問点」の5)、このことは、原告の主張とは逆に、東京都の課税基準が均衡を失するほど高額なものではなく、むしろ穏当な額に止められていることを自認したものだといえよう。

五 対象の限定と処分性

最後に、原告側は納税義務者を資金量5兆円以上の銀行業に限定したことの公平性を問題にしているが、一定規模以上の銀行業に「事業の状況に応じた」外形課税の必要性が認められる場合、その基準で課税業者の範囲を絞るかはやはり立法者の広い裁量に委ねられているし、被告は様々な分析を行った上で5兆円を基準にし、一定の合理性を示している。また、課税対象を限定する場合、どの基準で区分するかについては立法府に一定の裁量が従来から認められてきている。例えば、消費税の免税点の場合も、課税売上3000万円が基準であるが、なぜ3000万円なのか、それが不公平につながらないかが争われた東京地裁平成2年3月26日判決(判例タイムス722号222頁、判例時報1344号115頁、税務訴訟資料176号194頁)では、「年間売り上げ金額が3000万円以下の事業者が右制度により利益を得ることになり、右限度額の当否が租税政策目的上妥当であるか否かの問題はあろうが、立法上右制度による程度の差別が現段階で不合理であるとまでいいきれない」と判示されているし、住宅所得控除の適用対象となる最低床面積が改正により50平方メートルに引き上げられ、引き渡しが遅れたため特例対象とならなかったことの平等原則違反が争われた東京地裁平成10年2月26日判決(判例タイムス1000号275頁参照)でも「住宅取得控除のような住宅取得者に対する税制上の優遇措置を設けるかどうか、設けるとする場合にその制度内容をどのようなものにするかについても、立法府は広範な裁量権を有しているというべきである」と判示し、改正により適用に差が生じることについては「やむを得ないことであり、これをもって不合理な差別ということとはできない」としている。外形標準課税の適用要件を資金量5兆円以上の銀行業に限定した点についても、同様の判断基準が妥当しよう。

なお、原告側意見書の中では、本件条例が「過少包含」であるとしてこれを非難するものがあるが、その際の論拠は「例外4業種を除く全業種の中から…『銀行業等』だけが外形標準課税の対象となる」ことを指摘している(戸松鑑定意見書7頁)。しかし、同意見書がいうように「同じような状態にある者を同じように扱うこと」を前提にするなら、本件の場合には「全事業者」の中からではなく、「所得金額で課税するのが不合理な事業」の中から「銀行等」だけが対等とされたのかを問題にすべきである。また、原告側は銀行以外にも事業税収入が低下している業種がありながら、銀行だけに外形標準課税を導入したことを非難するが(原告第6準備書面18頁等)、被告が「事業の状況」に応じて銀行等に対して本件外形標準課税を導入したのは、単に事業税収入が低下しただけではなく、

「事業活動自体は業務粗利益に象徴されるようにバブル期より著しく増加しているにもかかわらず事業税負担の低下が著しい」（被告第2準備書面14頁参照）ためである。したがって、原告側は、銀行業等だけを対象とした東京都の理由に対して「銀行以外にも業務粗利益や売上粗利益等が著しく増加し、かつ、事業税負担が著しく減少している事業の存在」を根拠に反証すべきであるにもかかわらず、この点について何も反証していないといわねばならない。

また、原告は本件条例が課税対象を「資金量5兆円以上」の「銀行業」に限定しており、その結果わずか30行程度の銀行のみが対象になるという意味での「特定性」を有し、したがって行政処分と同視し、適正手続保障が及ぶ、としている（原告第6準備書面27頁）。特定者に対する課税を予定している条例の制定行為が抗告訴訟の適法要件としての処分性をもつことはあり得ると思われるが、そのことから当該制定行為を具体的課税処分と同視することまではできないであろう。なぜなら、納税義務者等が極めて少数になる立法例は従来から存在しており、例えば島根県や静岡県の核燃料税の場合は納税義務者は30行どころか、わずかに1社であり、また、国税の電源開発促進税もいわゆる電力会社が納税義務者であるので、日本全体でわずかに10社であるが、それらの制定行為が処分として理解され、手続保障がなされてきたわけではないからである。これらの条例・法律に基づく更正・決定等が処分性を有することはいうまでもなく、できるだけ適正手続を保障すべきだが、そのことと条例制定行為自体を同視することにはやはり無理があるといわねばならないであろう。以上の例は当該租税の課税対象全体が限定されている場合で、本件のように事業者のうち資金量5兆円の銀行に特定した場合とは異なる、という反論があるかもしれないが、念のため記しておく、酒税においても発泡酒のうちの特定の酒類に対する重課措置が特別措置法に定められている（措置法87条の4）。この特定の発泡酒の納税義務者は数社に限定されており、本件よりはるかに特定性が高いが、この制定行為が課税処分と同視されたことはないのである。

おわりに

以上の他に憲法上の争点もあるが、その大部分は事業税が「所得」課税であるかのような前提にたった議論なので、あえて取り上げる必要はないと思われる。本件条例は、以上のように、地方税法上の事業税の趣旨に則った適法なものであり、このような条例が地方税法の非体系的な解釈や政治的理由により制約されるならば、わが国の地方自治、地方分権化の流れは著しく損なわれてしまうであろう。

外形標準課税と訴訟の論点

三木義一（みきよしかず・立命館大学法学部教授）

はじめに

東京都が導入した事業税の外形標準課税問題が大きな波紋を投げかけている。この新税導入に対しては、納税者になる銀行側が強く反発しているが、他方で、通常は新税導入に抵抗感を示す一般市民が賛成している。銀行側が新税導入を不公平と非難すればするほど、それではあの「公的資金投入」は公平だったのか、という市民の素朴な疑問や怒りが新税導入を支えているようにも思われる。しかし、今回の外形標準課税導入は地方自治及び地方税制さらには税そのものに波及する様々な問題をも含んでおり、法的にも検討すべき課題は多い。本稿では、これらの問題のうち、銀行側が外形標準課税の違法性を訴訟上争う場合の税法上の争点に絞って検討してきたい。なお、訴訟上の問題としては、銀行側が課税処分を待たずに予防的な訴訟をした場合の訴訟技術上の論点もあるが¹、ここでは通常の課税処分取消訴訟で争われる場合の実体法上の争点に限定しておきたい。

一 課税対象・課税標準の選定と公平

今回の外形標準課税は東京都が法定外税制度を利用して新税を導入したわけではなく、現行の地方税法上72条の19の課税標準特例規定を適用したものである。従って、法律問題としては、当該規定の要件を満たしているかが最も重要な争点となるが、実質的には新税導入に近い内容を有しており、従来の判例が新税導入に際しての不公平論議等にどう対処してきたかをまず概観しておこう。

最高裁はすでに固定資産税の賦課期日制度の違憲性が争われた昭和昭和30年3月23日判決²で、「日本国憲法の下では、租税を創設し、改廃するのはもとより、納税義務者、課税標準、徴税の手続はすべて前示のとおり法律に基いて定められなければならないと同時に法律に基いて定めるところに委せられていると解すべきである。それ故地方税法が地租を廃して土地の固定資産税を設け、そして所有権の変動が頻繁でない土地の性格を考慮し、主として徴税の便宜に着眼してその賦課期日を定めることとしても、その当否は立法の過程において審議決定されるところに一任されているものと解すべく1月1日現在において土地所有者として登録されている者を納税義務者と確定し、その年度における納期において所有権を有する者であると否とを問わないこととした地方税法343条、359条の規定は、前記憲法の諸条規に適合して定められていること明であって、所論は結局独自の立法論にすぎない」として、立法府の裁量を広く尊重する姿勢を示している。この傾向は今日でも維持されており、法人の土地譲渡益重課税制度の平等原則違反が争われた東京地裁平成5年7月14日判決³はつぎのように述べ、最高裁⁴もこれを支持している。

「実質的平等は、きわめて抽象的かつ相対的な概念であるから、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件等との相関関係において判断され

¹ この問題点については、高橋滋「外形標準課税条例をめぐる訴訟法上の問題点」ジュリスト1181号、2000年7月1日、13頁以下で詳細に検討されている。

² 民集9巻3号336頁、税務訴訟資料22号448頁。評釈として、金子宏・別冊ジュリスト79号、1983年3月、10頁、松沢智・税経通信39巻15号、1984年12月、270頁、杉村章三郎・別冊ジュリスト4巻1号、1968年2月、8頁等参照。

³ 税務訴訟資料198号146頁。

⁴ 平成8年1月26日判決・税務訴訟資料215号170頁。

るべきものである。そこで、右要請を現実の立法として具体化するには、高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断とを要するから、右実質的平等の趣旨にこたえて立法措置を講ずべきか否か、またその具体的内容の選択決定は、立法府の幅広い裁量に委ねられている。したがって、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所がこの点につき審査判断することはできない。たしかに、総合所得の観点からのみみれば、他の事業の欠損との差引勘定により総合所得がない場合にも、これとは別に土地譲渡益を取り上げて重課税を課すのは、土地譲渡益のない法人との間で前示のとおり、等しい担税力をもつ納税者は等しい税負担を負うという水平的公平ないし形式的平等に反するといえなくもない。また、土地重課規定は、法人の他の事業所得と合算せず、土地の譲渡益に担税力を見出したものであるから、これが憲法14条1項の実質的平等の要求を具体化した規定という余地もある。しかし、法人の担税力の指標を法人の全所得を通算した最終的な総合所得額にのみ求めなければならないという法的根拠はない。前示のとおり、租税の分野において所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、立法目的が正当で、かつ、区別の態様がその目的と関連性を有し不合理でない限り、形式的平等の要請はもとより、とくにそれが実質的平等の実現の当否に関する場合には、基本的に、それは広範な立法裁量に委ねられている。そして、土地譲渡益に担税力を見出した土地重課規定の立法目的の正当性、その手段の合理性等に照らし、土地重課規定が著しく合理性を欠き、明らかに立法裁量の逸脱・濫用とは認められないことは前示のとおりである」。

このように、立法府の課税権限に対して、その是非は別として、裁判所は従来その介入に消極的な姿勢をとり続けてきている。地方税条例についても、自治体の立法権限については国税との抵触がない限り、基本的には立法裁量を尊重すると思われるので、今回に限って積極的に立法内容に司法が介入するとは思われない。このことを前提に、つぎに地方税法72条の19との関係を具体的に検討してみよう。

二 銀行側の批判と外形標準課税

地方税法72条の12は法人の事業税の課税標準を大きく二つにわけ、電気・ガス供給業、生命保険・損害保険業に対しては収入金額、その他の事業に対しては所得金額及び清算所得としている。ただし、その他の事業及び個人であっても、「事業の状況に応じ」所得及び清算所得にはよらないで、「資本金額、売上金額、家屋の床面積もしくは価格、土地の地積もしくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は、所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせもちいるができる」とされている（地方税法72条の19）。この規定を根拠に事業年度末の資金量5兆円以上の銀行業及びそれに類似する事業を営む法人に対し、5年間の時限措置として、「業務粗利益」（資金利益＋役務取引等利益＋その他業務利益）に3%の税率で課税しようとしたことになる。これに対して、全国銀行協会は平成12年3月7日に7つの疑問⁵（以下、「疑問」と略す）を提示し、今回の外形標準課税の違法性・

⁵ 平成12年3月7日全国銀行協会「都の答弁・説明に対する7つの疑問点～大手銀行への外形標準課税導入について」

違憲性を指摘している。これに対し、東京都も3月9日に反論⁶（以下「反論」と略す）をしている。両者の対立は内容的にはつぎの4点に要約できるので、以下それぞれの論点を概観しておこう。

1) 納税者への説明義務過怠

銀行側は東京都による事前の説明があまりに不十分だったこと、また、新税に関する情報の開示を要求したがほとんどなされておらず、新税導入についての立証をしていない、と批判している（「批判」1参照）。これに対して、東京都は十分な説明を行ってきたと反論し、いわば水掛け論になっている。課税される者が、その合理的な理由について納得できるような説明を求めること自体は当然のことであろうが、銀行側の主張が立法者の説明不十分を新税の違法性の根拠にしようとしているのか必ずしも明確ではない。課税される者の個別の事前了解が新税導入の合憲要件とは一般にはいえないし（もし、そうなら新税導入は不可能であろう）、知事の独断で立法できるならともかく、今回の新税導入も都の税条例設定手続をへて導入されているので、その過程においては議会での審議がなされ、その意味では租税法律主義・租税条例主義の要請はみたしている。その結果が、仮に市民の多数の希望と異なっているとしても、そのことを理由に新税が違憲となることはないといわざるをえない。消費税導入が国民の意思に反するという理由で争われた事件で、広島高裁平成3年12月5日判決⁷は「憲法前文及び1条は主権が国民にあることを明定するところ、立法について、同法41条は『国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。』と規定するとともに、同法43条1項は『両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。』と規定して、いわゆる間接的民主制を採用しているから、本件消費税法が国民の意思に反する旨の政治的批判をすることはともかくとして、法律的には、本件消費税法が国会において可決された以上、それは国民の意思に基づくものと看做されるべきである。仮に、裁判所において本件消費税法が国民の意思に反するや否やにつき証拠調べができるとする考え方があるとすれば、それは間接的民主制を定めた憲法の前記規定を無視するものといわざるを得ない」と判示している。地方税における地方議会の役割も同様であろう。

したがって、説明努力過怠は、仮にあったとしても、それは立法者の政治責任を問うにとどまり、新税の法的効力を左右するものではないと思われる。

2) 事業の状況

地方税法上の解釈問題として、外形標準課税が許される「事業の状況」とは何か、という論点がある。銀行側は、この事業の状況というのは①制度上、②収益構造上の客観的な特性をさし、電気・ガス供給業の場合は料金が認可制で低くおさえられていること、保険業の場合は配当利益のウェイトが高いのに所得計算上益金に算入されていないこと、他方で契約者配当が事業所得計算上は損金の額に算入される等の収益構造上の理由があるのに

⁶ 平成12年3月9日東京都主税局「全国銀行協会『都の答弁・説明に対する7つの疑問点について』への都の考え方」

⁷ 税務訴訟資料187号236頁。

対し、銀行についてはそのような特性がないこと（「批判」2）、また、事業税を負担していない業者は銀行業だけではない、（「批判」3）等の批判をしている。これに対し、東京都は「事業の状況」の意味を右のようなものに限定する根拠はないし、十分な収益をあげながら行政サービスの対価としての事業税を負担していないことも事業の状況に含まれること、バブル期よりも本業で利益（業務粗利益）をあげながら、不良債権処理のために事業税を負担していないのは銀行業だけであると反論している。

この問題は、銀行業に対する外形標準課税が合理性を論証するための重要な点であり、この点を合理的に説明できないと銀行業だけをねらい打ちにした不公平な課税という非難を避けることはできない⁸。この外形標準を許す「事業の状況」の意味内容は、事業税の本質との関係から検討されるべきものであろう。事業税は明治29年に創設された営業税を前身とし、課税客体は事業であり、事業そのものの経済的価値に担税力を見出している税として一般に解されており⁹、所得そのものに課税するものではない。したがって、事業税の課税標準として「所得」が本質的に望ましい基準では必ずしもなく、事業そのものの価値や収益力を計るひとつの目安に過ぎない。したがって、私見によれば、外形標準を許す「事業の状況」というのは、事業税の趣旨からみて所得で課税するとかえって不公平になる事情を広く含む概念であると思われる¹⁰。そうすると、銀行業が本業である業務粗利益で利益を多額に得ていること、それが不良債権処理を促進するための政策的な措置で所得金額が減っていることなども当然事業の状況の判断する一要素ということになろう。私見によれば、決定的なのは、所得がないとしながら平成10年度で大手銀行が2600億円もの配当をしている事実であろう（「反論」3）。配当し得るだけの余力がありながら、事業税を負担していないことを市民にどう説明するのだろうか。公的資金の提供をうけ、業務粗利益はあがっているのに事業税を負担せず、しかも株主配当はちゃんと行っている、ということを経営者に合理的に説明できるのだろうか。こうした事実を見る限り、銀行業に対して所得以外の基準で課税標準を設定する「事業の状況」は存在しているといつてよいように思われる。

3）所得等を課税標準とする場合との均衡

地方税法72条の22では外形標準課税が通常の所得等による課税の場合に比して「著しく均衡を失することのないようにしなければならない」と規定しているので、この意味での不均衡があってはならないことになる。東京都は過去15年の銀行業における事業税収の実績を勘案して、所得課税との均衡を図りつつ税率を定めたとしている（「反論」4）。これに対し、銀行側は税率3%がバブル期の影響を受けた時期の税収を織り込んで税率を

⁸ この点を強調し、新税の公平性を疑問視するものとして水野忠恒「東京都外計標準課税の評価」ジュリスト1181号、2000年7月1日、6頁。

⁹ 例えば、前川尚美・臼井守・小川徳治『地方税・各論Ⅰ』（ぎょうせい、1988年）248頁参照。

¹⁰ 神野直彦「外形標準課税と地方分権」ジュリスト1181号、2000年7月1日、111頁が「法人利潤を課税標準とすることが、法人事業税の本来の性格、つまり事業活動に規模に応じた課税という本来の性格として相応しくない負担状況が生じた場合」としているのも同趣旨と思われる。

定めており、恣意的であると批判し（「批判」4）、また政府見解も東京都案には所得課税の場合との均衡から見て疑問であるとしている¹¹。この規定の「均衡を失してはならない」とは何と比較してなのかがまず問われねばならないであろう。仮に、この規定を現実の所得金額を課税標準とした場合と比較して均衡を失してはならない、という意味に理解するなら、外形標準課税の存在理由はなくなる。外形標準で課税するのは、各業種で算定される現実の所得では当該事業の担税力を適切に表せないと判断されたからこそであり、この場合の税収が現実の所得に課税した場合と差がでないようにしなければならないのであれば、外形標準課税をする意義は失われてしまうのは明らかであろう。したがって、この「均衡」は当該事情の現実の所得ではなく、当該事業におけるあるべき所得との対比において検討されるべきものであろう。銀行業務において通常考えられる所得に対して課税する場合と、今回の外形標準課税の税収とは、東京都の説明では過去15年の所得に課税していた時代の税収実績を勘案したものであり、所得で課税する場合との均衡を失しているとはいえないであろう。かえって、銀行側がこれまで多額の納税実績があり、東京都の業務粗利益×3%を基準にすると過去20年間で3800億円もの支払い超過があると主張しているのは（「批判」5）、東京都の課税基準が均衡を失するほど高額なものではなく、むしろ穏当な額に止めたことがわけるといえよう。

4) 資金量5兆円

最後に、銀行側は納税義務者を資金量5兆円以上の銀行業に限定したことの公平性を問題にしている（「批判」7）。これに対して、東京都は5兆円以上の銀行の資金量が金融機関全資金量の5割を超えている、資金量5兆円以上の銀行の業務純益が銀行の業務純益の7割を超えている、等の反論を展開している。東京都の反論が、5兆円に限定することの説得力を有しているとは必ずしも思えないが、どの基準で課税業者を選択するかはやはり立法者の広い裁量に委ねられているといわざるをえない¹²。消費税の場合も、課税売上3000万円が免税か否かの基準であるが、なぜ3000万円なのか、それが不公平につながらないかが争われた東京地裁平成2年3月26日判決¹³は「年間売り上げ金額が3000万円以下の事業者が右制度により利益を得ることになり、右限度額の当否が租税政策目的上妥当であるか否かの問題はあろうが、立法上右制度による程度の差別が現段階で不合理であるとまでいいきれない」としている。課税するかどうかを一定の基準で区別する場合、ボーダーライン上の当事者には不公平感がつきまとうが、立法的に一応の合理性が示されている以上、その基準を根拠に当該法令の違憲を主張するのは難しいともいわれる。本件の場合も、5兆円で区別する一応の理由が示されている以上、5兆円の基準に業務粗利益に課税すると新税導入の趣旨を損なうような著しい不合理が生じることを具体的に指摘で

¹¹ 平成12年2月22日付「銀行業等に対する東京都の外形標準課税について」の2参照。

¹² 立法技術的には、納税義務者を銀行業全体にし、中小業への配慮から資金量5兆円以下の銀行業は免除するような方法の方が無難ではあったと思われる。

¹³ 判例タイムズ722号222頁、判例時報1344号115頁、税務訴訟資料176号194頁。評釈として、阿部泰隆・租税判例百選<第3版>、1992年12月、126頁、吉良実・シュトイエル347号、1991年2月、1頁、小林武・法学セミナー35巻8号、1990年8月、113頁、等参照。

きない限り、外形標準課税を違憲・違法にすることはできないと思われる。

三 外形標準課税と「税」の本質

以上のように、銀行側と東京都の議論を比較検討する限り銀行側の主張に説得力があるとは思われない¹⁴。しかし、東京都が導入する外形標準課税が税法の立場から見て本当に望ましい税制なのかという点については、やはり検討しておかねばならない。特に赤字の中小法人からはこのような課税方式が一般化することには、所得なきところに課税とするという意味での抵抗が強い。確かに、所得があつてはじめて税負担が可能で有り、応能負担を実現する基準としては所得がベストだと考えると、外形標準課税にはやはり抵抗感であろう。私見も応能負担を図る基準としては所得が優れていると考えているが、外形標準課税が憲法14条の応能負担原則に直ちに抵触するとはいえないようにも思われる。私見によれば、租税は基本的には国家や自治体が整備した市場を利用することに対する対価であり、それ故、所得税の対象となる所得は市場を媒介として得られた利得に限定されるべきだと考えている¹⁵。この観点からは法人税は市場を利用して得られた成果に対する課税で、結果として所得を得られなかったものは負担する必要がないが、事業税は法人税のような市場利用の成果に対する課税とは異なり、市場を利用するための一種の利用料的負担であると解することができるのであるならば¹⁶、当該利用料的租税負担は結果としての所得よりも利用規模としての外形標準を課税標準にする方が負担能力を適切に表しうる場合もあるようにも思われるからである。外形標準課税の一般化はその意味で租税というものの本質を改めて考えさせることになるう。

おわりに

以上、東京都の外形標準課税の実体税法上の論点を両当事者の主張を中心に検討してみた。外形標準課税に全く問題がないわけではないが、少なくとも今回の外形標準課税導入が違憲・違法とはいえないように思われる。むしろ、東京都が自治体として独自の課税権限を行使したことは、地方自治確立の観点からは望ましい。もちろん、この税の他府県に与える減収効果やこのような課税は東京都のような大都市でしかできないこと、等の問題点もあるが、自主課税権強化の過程で派生した問題として、自治体間の協議と各自治体の課税権強化の中で調整すべき課題でもであろう。石原知事がかつて批判してきた美濃部知事と課税面では同じような行動をとったこと自体興味深いが、このことは地方自治と地方税・財政の矛盾がいかに大きいかを改めて物語っているようにも思われる。

¹⁴ 東京都の外形標準課税を支持する立場からの財政学的論拠については、青木宗明・神田誠司『東京都の「外形標準課税」はなぜ正当なのか』（公人の友社、2000年）、山田雅俊「租税論の今日的課題」税2000年4月号4頁以下、等参照。

¹⁵ このような所得概念は近時ドイツで有力に主張されている。この所得概念の詳細については、奥谷健「市場所得説の生成と展開(一)(二)」民商法雑誌122巻3～4号、2000年6月～7月、を参照。

¹⁶ 青木・神田・前掲書では「ショバ代」と表現している（6頁）。

